

1501028-66.2019.8.26.0129
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL
Comarca: Casa Branca
Foro: Foro de Casa Branca
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... agentes. A este respeito:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Preliminar. Inépcia denúncia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para os tipos penais previstos nos artigos 28 e 37 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento prevista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Casa Branca
Foro de Casa Branca
2ª Vara
Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501028-66.2019.8.26.0129 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501028-66.2019.8.26.0129
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2330794/2019 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 5295614 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 615/19/200 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2330794 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 615/19/200 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2330794 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 615/19/200 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONCALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

CRISTIANO DOS SANTOS DE FREITAS e CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONÇALVES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia:

1 - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, a partir de meados de

2019, na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", localizada nesta cidade e Comarca de Casa Branca, CRISTIANO DOS SANTOS DE FREITAS, qualificado a fls. 47, e CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONÇALVES, qualificada a fls. 94 e ss., associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 2 - Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2019, por volta de 08h, na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", localizada nesta cidade e Comarca de Casa Branca, CRISTIANO DOS SANTOS DE FREITAS, qualificado a fls. 47, e CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONÇALVES, qualificada a fls. 94 e ss., em unidade de desígnios e acordo de vontades entre si, traziam consigo e ocultavam, para entrega a consumo de terceiros, 6,1g (seis gramas e um decigrama) de ADB-FUBINACA, popularmente conhecida como "maconha sintética", substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls.05 laudo químico-toxicológico a fls.07/09). Segundo se apurou, o denunciando CRISTIANO estava preso em cumprimento de pena na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", aqui situada, e, visando introduzir drogas no interior do referido estabelecimento prisional, com o intuito de entregá-la dentro da penitenciária a consumo de outros presos, associou-se à denuncianda CRISTIANE e combinaram que ela, CRISTIANE, levaria a droga acima referida para ele, CRISTIANO, com o intuito de vendê-la e distribuí-la dentro da Penitenciária a outros presos. Assim combinado, aproveitando da visita que realizaria ao denunciando CRISTIANO, CRISTIANE escondeu duas cartelas, constituídas de papéis, contendo a droga sintética ADB-FUBINACA, pesando 6,1g, em um pote plástico que continha misturado arroz e carne, a fim de entregá-la no interior da penitenciária ao denunciando CRISTIANO, que distribuiria a droga para consumo dos demais presos. Quando ela ingressava no estabelecimento prisional, contudo, a denuncianda CRISTIANE teve seus pertences revistados, quando agentes penitenciários localizaram referidas cartelas com a droga supra descrita, misturadas à comida antes referida, que foram apreendidas. Vale dizer que o local da apreensão, a quantidade, a natureza e acondicionamento da droga, e as circunstâncias da prisão demonstram o fim de mercancia, de modo a caracterizar o crime de tráfico e de associação ao tráfico descrito nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 147 e 156).

Resposta à acusação apresentada as fls. 157/158 e 162/163.

Durante a fase instrutória, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e interrogados os acusados ao final.

A i. Representante do Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 221/228).

Por sua vez, a nobre Defesa de Cristiano dos Santos de Freitas requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e autorização para recorrer em liberdade (fls. 233/239).

A Defesa de Cristiane Aparecida da Rocha Gonçalves protestou: pela absolvição da ré do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343.06, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código Penal; e pela absolvição da ré do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343.06 nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Por fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de redução de pena descrita no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e fixação de regime inicial mais brando (fls. 240/246).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo apura a materialidade e autoria dos episódios criminosos narrados na denúncia, condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de

forma regular, tendo sido respeitados todos os preceitos constitucionais e legais. Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que o pedido formulado na presente ação penal é procedente em parte.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, não há provas suficientes para a condenação. Isso porque a prisão decorreu de flagrante, não tendo havido acompanhamento da atividade no tempo.

Com efeito, inexistente comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente, não sendo suficiente para caracterização a apreensão de grande quantidade de drogas. Não consta dos autos elementos sobre a organização do grupo, sobre a divisão de funções entre seus membros, sobre eventual relação de hierarquia entre eles tampouco acerca da mínima estruturação entre os agentes. A este respeito:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Preliminar. Inépcia denúncia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para os tipos penais previstos nos artigos 28 e 37 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 caracterizada. Condenações mantidas. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Dosimetria. Reajuste do incremento das basilares em 1/5. Multirreincidência do réu Wesley. Incidência do inciso III do art. 40 da Lei de regência. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Réu Wesley multirreincidente e dedicação de Diego a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido. Inviabilidade da redução da pena de multa. Fixação observados os parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1502786-74.2019.8.26.0616; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2021; Data de Registro: 11/09/2021) Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico - Recursos defensivos e ministerial - Matéria preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas do tráfico - Absolvição - Descabimento - Impossibilidade de condenação, no que se refere ao delito autônomo de associação para o tráfico, pela inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes do imputado vínculo estável e permanente entre os agentes - Dosimetria redimensionada, pelo reconhecimento de circunstância agravante, cuja natureza é objetiva - Pena de Jefferson recrudescida, também, em razão do necessário acolhimento de circunstâncias judiciais negativas, a teor do artigo 42, da Lei Antidrogas - Reprimenda do réu Kleber majorada pelo afastamento do privilégio legal, diante do desfavorecimento das circunstâncias concretamente aferidas, que evidenciam dedicação à mercancia ilícita - Regime prisional de Kleber recrudescido, a fim de guardar proporcionalidade com as peculiaridades delitivas - Sentença reformada nessa extensão - Recursos defensivos desprovidos e insurgência ministerial parcialmente acolhida. (TJSP; Apelação Criminal 1501413-38.2020.8.26.0530; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Impõe-se, portanto, a absolvição por falta de provas.

Diversamente, em relação ao tráfico de drogas, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por intermédio da Portaria (fls. 02), do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do auto de exibição e apreensão (fls. 05), da cópia do procedimento apuratório de falta disciplinar (fls. 18/85), do relatório final (fls. 102/103), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 07/09) e dos depoimentos carreados aos autos.

A autoria também é certa e recai sobre as pessoas dos acusados.

Rogério Rezende Ribas de Ávila Filho, agente penitenciário, contou que é o diretor do setor de portaria do presídio local; no dia dos fatos, o funcionário Adilson lhe chamou e contou que havia encontrado duas cartelas com drogas dentro de um vasilhame transparente em meio aos alimentos; Adilson detalhou que a vasilha passou

pelo scanner e apresentou uma imagem inconclusiva, motivo pelo qual decidiu averiguar; Adilson indagou a visitante que trazia a vasilha consigo; a visitante disse que do lado de fora da unidade, uma mulher havia pedido para ela ingressar com a vasilha na penitenciária; acrescentou que as drogas aparentavam ser sintéticas; é agente penitenciário há vinte e dois anos; a droga dentro da unidade prisional é mais cara do que nas ruas; Cristiane estava devidamente cadastrada no rol de visitas de Cristiano; não havia denúncias sobre Cristiane, no sentido de que ela levaria drogas ao companheiro.

O diretor de segurança e disciplina da penitenciária, Fabio Gizzi de Marque, disse que não presenciou os fatos; na ocasião, durante a passagem pelo scanner dos produtos que a visitante Cristiane trazia ao preso Cristiano, os funcionários responsáveis pelo setor de portaria, constataram uma imagem suspeita numa vasilha que continha alimentos; o funcionário decidiu fazer uma revista manual e encontrou duas cartelas de droga sintética conhecida como K4; indagada, Cristiane disse que não sabia do que se tratava e que tinha pego a vasilha de alimentos do lado de fora da unidade prisional; a droga dentro do presídio tem valor muito maior do que nas ruas; a organização criminosa denominada "pcc" é a principal responsável pelo comércio de drogas dentro dos presídios; não tinha denúncias anteriores sobre a prática de tráfico de drogas com relação ao preso Cristiano; Cristiane visitou Cristiano aproximadamente sete ou oito vezes; explicou que é comum que pessoas do lado de fora da unidade contratem visitantes para introduzir as drogas no presídio. A acusada Cristiane Aparecida da Rocha Gonçalves na fase administrativa, relatou que é companheira de Cristiano, recolhido no presídio de Casa Branca; mora em Amparo; na data dos fatos veio para Casa Branca visitar seu companheiro; do lado externo da penitenciária foi abordada por uma mulher que dizia ser visitante também; ela lhe pediu para entregar uma vasilha de comida para presos que não possuem visitas; aceitou levar a vasilha; ao passar pela portaria, seus pertences foram vistoriados e os agentes encontraram drogas sintéticas dentro da vasilha da referida mulher; não conhece e não possui amizade com a referida mulher; desconhecia a existência das drogas dentro da vasilha (fls. 10/11). Em Juízo, disse que, no dia dos fatos, estava do lado de fora da unidade, quando uma senhora lhe pediu para entrar com uma vasilha de alimentos transparente na unidade; essa vasilha de alimentos seria entregue para presos que não têm visitas; a senhora orientou que entregasse a vasilha ao marido, dizendo que era o "tupperware dos peregrinos" e "entrega pra ele, que ele vai saber o que fazer"; nas visitas sempre levava o máximo de vasilhas permitido, ou seja, três; nesse dia dos fatos estava com duas vasilhas, motivo pelo qual aceitou o pedido da senhora; essa senhora não lhe ofereceu dinheiro; iria fazer um favor; na revista, os agentes encontraram as drogas sintéticas; não tinha ciência das drogas; a vasilha era transparente; na época dos fatos era companheira do Cristiano; após os fatos, ele resolveu excluí-la do rol de visitas; manteve relacionamento com Cristiano por quatro anos; visitou Cristiano muitas vezes, ia toda semana; visitou ele em Capela do Alto, Mairinque, Hortolândia, P4, P3 e em Casa Branca; nunca se casou com Cristiano; era amásia dele; é solteira; tem dois filhos maiores de idade; trabalha com canil; Cristiano sempre lhe pedia para pegar a "vasilha do peregrino" do lado de fora da unidade; não sabe dizer se Cristiano tinha ciência da existência das drogas dentro da vasilha.

O acusado Cristiano dos Santos de Freitas na fase de inquérito, relatou que uma semana antes havia recebido a visita de sua companheira; não sabia se ela viria novamente; no dia dos fatos, no período da manhã, foi informado pelo agente que sua visita havia sido surpreendida com drogas em meio aos itens que trazia; nega que tenha solicitado drogas a sua companheira; possui união estável com Cristiane há aproximadamente seis anos; não possuem filhos em comum; fazia parte do "pcc", mas foi excluído há cerca de três meses (fls. 62). Em Juízo, disse que não esperava visitas no dia dos fatos; tomou conhecimentos dos fatos através de funcionários da unidade; não tinha ciência da existência das drogas; estava preso por tráfico de drogas; mora em Amparo com sua amásia; tem dois filhos menores de idade; trabalha na construtora Barbosa; saiu do presídio em janeiro de 2021; sempre alertava Cristiane para tomar cuidados com pessoas do lado de fora da unidade; nunca pediu

para Cristiane pegar marmitas do lado de fora da unidade.

Realmente, a despeito das versões apresentadas pelos acusados, dos depoimentos trazidos aos autos e dos elementos de provas carreados, retira-se que Cristiane Aparecida da Rocha Gonçalves trazia consigo e ocultava, cerca de 6,1g (seis gramas e um decigrama) da droga ADB-FUBINACA (maconha sintética), a fim de entregar ao corréu Cristiano dos Santos de Freitas, atendendo ao pedido deste, que iria revender as substâncias aos demais reeducandos.

Das provas carreadas aos autos, reputo devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado aos réus. É que ficou nítido que Cristiane trazia as drogas para entrega ao seu companheiro e que ele posteriormente as distribuiria no interior de um estabelecimento prisional que conta com cerca de dois mil presos.

As palavras dos agentes penitenciários devem ser acatadas por merecerem crédito. De fato, são servidores públicos, concursados, nos quais o Estado deposita confiança para desempenho do mister. Seria verdadeira contradição o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, afastar ou diminuir o valor das palavras dos agentes públicos que apuraram os fatos. Saliento que nada nos autos indica o desejo dos servidores de imputar condutas tão graves aos réus de maneira inverídica. Nesse sentido, exemplo da farta jurisprudência:

“As palavras dos agentes penitenciários e do chefe de segurança do presídio devem ser acatadas, pois são servidores públicos, nada indicando desejo de imputar condutas tão graves aos réus de maneira leviana. Nesse sentido, exemplo da farta jurisprudência: E esses testemunhos, aliados às condições em que se deu a apreensão do entorpecente, não deixam dúvida quanto à intenção de praticar a traficância no interior do estabelecimento prisional. Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos agentes penitenciários, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha.”. (Apelação TJSP nº 0004237-69.2012.8.26.0483 - Comarca: Presidente Venceslau - Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal - Relator Ivan Sartori).

“APELAÇÃO CRIMINAL CORRUPÇÃO ATIVA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA VERSÕES CONTRAPOSTAS NADA A RETIRAR A CREDIBILIDADE DO RELATO DO AGENTE PENITENCIÁRIO NARRATIVA QUE SE SOBREPÕE À SIMPLÓRIA NEGATIVA DO DETENTO (...).” (TJSP, Apelação nº 0015216-47.2010.8.26.0229, 6ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Euvaldo Chaib, J. 11.09.2015).

“A palavra dos agentes penitenciários não pode ser descartada somente em razão da profissão exercida pelas testemunhas, sendo necessário, para que se coloque em dúvida tais depoimentos, a presença de indícios sérios e idôneos nesse sentido, o que não ocorreu no caso.” (Apelação TJSP nº 0000356-97.2015.8.26.0283, Julgado em 24/09/2018, 2ª Câmara, Relator: Sergio Mazina Martins, DJe. 03/10/2018).

“Vale ressaltar que os relatos dos agentes penitenciários envolvidos na apreensão das drogas são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis”. (Apelação nº 1501774-69.2018.8.26.0548 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. César Augusto Andrade de Castro - julgado em 04/12/2019).

Os réus negaram a prática do tráfico de drogas, porém não deram qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos. A tese de autodefesa dos acusados de que não tinham ciência da existência das drogas não deve prosperar, vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos.

Como se vê, as declarações dos acusados não demonstraram harmonia com a dinâmica

dos fatos comprovados nos autos e as versões dadas por eles são dissonantes do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrarem respaldo fático. Percebe-se, enfim, nos discursos, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual as versões por eles apresentadas não podem ser aceitas.

Consigno, por oportuno, que é cediço que pode haver pressão ou até mesmo ameaças pelos sentenciados para que seus familiares entrem com drogas no interior dos presídios. A adesão ao pedido, porém, é opção do familiar. No caso em questão, a acusada preferiu aderir ao pedido do companheiro, levando a substância ilícita a ele, com nítido dolo de ingressar no presídio levando drogas que sabia que seria destinada ao comércio.

Destaco que a traficância foi confirmada em Juízo pelas testemunhas de acusação, em especial pelo depoimento do diretor de segurança e disciplina da unidade prisional, que explicou que é comum que as visitas dos presos sejam abordadas do lado de fora e contratadas para ingressar com drogas na unidade prisional. De fato, tal prática foi confirmada pela apreensão de farta quantidade de entorpecentes com a visitante, o que indica claramente o envolvimento de ambos no comércio espúrio.

Por oportuno, consigo que opera-se o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso em tela. A vistoria nas visitantes e em seus pertences, ainda que minuciosa, dificulta a entrada de entorpecentes na penitenciária, mas não a torna impossível. Do contrário, não haveria tantos procedimentos de igual natureza no sistema prisional.

Além disso, o crime se consumou nas modalidades trazer consigo e ocultar, do que se extrai que antes mesmo da apreensão das drogas pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado, sendo desnecessário que a droga de fato ingressasse no presídio. Esse tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

“Inicialmente, buscam os Apelantes suas absolvições, aduzindo se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, isso porque a existência de scanner no estabelecimento prisional impediria, de qualquer forma, a consumação do crime. Para caracterização de crime impossível, é necessário não existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que não ocorreu no caso dos autos. O fato do estabelecimento prisional possuir um scanner na revista, o que impediria o ingresso de materiais não permitidos, não é garantia de que JULIANE não conseguiria atingir seu intento”. (Apelação nº 1500429-58.2019 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Luis Antônio Cardoso – julgado em 03/12/2019).

“Ademais, a conduta é típica, ainda que o apelante não tivesse conseguido efetivamente tomar posse da droga dentro do presídio. Desta forma, sendo o tráfico de drogas um tipo penal de conteúdo misto alternativo, qualquer das condutas descritas em seu preceito primário tipifica o delito”. (Apelação nº 1500321-58.2018.8.26.0283 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Tozola Neto – julgado em 12/12/2019).

“Ademais, não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente do acusado, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, adquirir e remeter entorpecentes para consumo de terceiros, o que no caso restou comprovado”. (Apelação nº 1501687-79.2018.8.26.0624 – 11ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Guilherme G. Strenger – julgado em 04/09/2019).

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câ., j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Assim, o crime já estava consumado quando a droga foi encontrada pelos agentes

penitenciários, independentemente da acusada lograr transmitir o entorpecente ao seu companheiro.

Nesse passo, de rigor a condenação dos acusados para o crime de tráfico de drogas, visto que, embora Cristiano não tenha podido praticar a conduta de entregar a droga a terceiros como pretendia, solicitou que sua companheira lhe trouxesse o entorpecente, com ela, pois, praticou o delito. E, sem sombra de dúvidas, este foi o panorama em que se deram os fatos: buscou o acusado o auxílio de sua companheira para fazer com que a droga pudesse ingressar no interior do presídio e, assim, distribuí-la aos demais reeducandos.

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isentem os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

No que concerne ao acusado Cristiano dos Santos de Freitas:

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta Maus antecedentes (fls. 129/130 - processo nº 0006497-76.2014.8.26.0022). Destaco que, apesar de pequena quantidade em termos de massa, a droga apreendida é sintética. Não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à conduta social e personalidade do acusado, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, considerando as circunstâncias mencionadas, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, presente a agravante da reincidência (fls. 130 - processo nº 0008630-91.2014.8.26.0022) e, ausentes as atenuantes, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 e, não havendo causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Outrossim, deixo de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é reincidente e portador de Maus antecedentes.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, em consideração aos Maus antecedentes, à reincidência e à gravidade em concreto da infração.

Igualmente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, em razão do montante da pena aplicada, da reincidência e dos Maus antecedentes.

No que concerne à acusada Cristiane Aparecida da Rocha Gonçalves:

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que a acusada é primária (fls. 126/127). Não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à conduta social e personalidade da acusada, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a natureza da droga não será considerada nesta primeira fase, pois servirá como fundamento para a dosagem do redutor do redutor do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem.

Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes as agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 (um sexto) e, não havendo causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, tendo em vista que a natureza das drogas, por si só, não impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (a propósito: AgRg no AREsp 1955819/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022), impõe-se o reconhecimento do privilégio. De todo modo, a acusada portava droga de natureza sintética (ADB-FUBINACA) para tentar ingressar no interior de um estabelecimento prisional, de forma que o redutor será fixado no patamar de 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa ..." (STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016)

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) limitação de fim de semana, pelo prazo da condenação, nos moldes a serem indicados no duto Juízo das execuções e; b) prestação de serviços à comunidade.

Os acusados responderam o processo em liberdade e, não se fazendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, mantenho o benefício em respeito ao princípio da contemporaneidade e autorizo que recorram deste pronunciamento em liberdade.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PEDIDO o pedido da presente ação penal, para o fim de:

a) condenar CRISTIANO DOS SANTOS DE FREITAS, qualificado nos autos, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no mínimo legal.

b) condenar CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONÇALVES, qualificada nos autos, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput e § 4º c/c artigo 40, inciso

III da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal, observada a substituição supra.

c) absolver os réus CRISTIANO DOS SANTOS DE FREITAS, qualificado nos autos, e CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA GONÇALVES, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art.58, §1º c.c art.32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em prol do ilustre Advogado que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado: 1- comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2- lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3- oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); 4 - expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado para atuar no feito; 5 - intimem-se os condenados para efetuarem o pagamento da multa imposta na sentença; 6- formem-se os processos de execução para cumprimento das penas aplicadas, encaminhando-se o ao Juízo competente para tanto e 7- arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Casa Branca, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA